

<제4편 소송의 종료.제10장 중국판결에 의한 종료.제02절 판결>

[기출][2019-1-2]확정판결의 기판력과 표준시 이후의 상계권 행사 가능성

《【문제1】 甲은 乙에 대하여 지급기일을 2017. 2. 1.로 하는 1억 원의 공사대금채권을 가지고 있었다. 乙은 2017. 10. 1. 이 채권금액 가운데 3,000만 원을 변제하였다. 甲은 2018. 4. 1. 乙에 대하여 위 공사대금 1억 원의 지급을 구하는 소를 제기하였다. 법원은 2018. 12. 1. 변론을 종결하고 甲의 청구대로 1억 원의 지급을 명하는 판결을 선고하였고, 그 판결은 확정되었다. 다음 물음에 답하시오. (50점)》

(물음2) 乙은 甲에 대하여 2018. 5. 1.을 지급기일로 하는 대여금 2,000만 원의 채권을 가지고 있었으나 상계항변을 하지 않았다. 乙이 2019. 7. 1.에 이 채권을 가지고 상계할 수 있는지를 논하시오. (20점)》

<문제1의 물음2> 확정판결의 기판력과 표준시 이후의 상계권 행사 가능성

I. 문제의 제기

- 사안에서 乙은 공사대금 청구소송 계속 중 이미 변제기가 도래한 자신의 대여금채권을 가지고도 상계항변을 하지 않은 채 甲 승소의 확정판결이 이루어진 후 다시 그 채권으로 상계하려는 상황이다. 쟁점으로 <확정판결의 기판력이 변론종결 전 존재하였으나 행사하지 않은 상계권의 행사에 미치는 효력과 판결 확정 후 상계의 허용 여부>를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 변론종결 전 발생한 상계권에 대한 실효의 적용 여부와 판결 확정 후 乙의 상계 가능 여부를 논한다.

II. 기판력의 시적 범위와 차단효

1. 기판력의 표준시

- 기판력은 무한정 인정되는 것이 아니라 특정 시점의 권리관계를 확정하는 것이다. 민사소송법상 사실심 변론종결 시를 기준으로 하며, 이를 기판력의 표준시라고 한다. 표준시 이전에 발생한 사유는 이후의 소송에서 더 이상 다룰 수 없게 되는데 이를 기판력의 차단효 또는 실효효과라 한다.

2. 차단효의 범위

- 당사자는 표준시 이전에 존재했던 모든 방어방법을 소송 절차 내에서 제출했어야 한다. 이를 게을리하여 판결이 확정된 경우, 설령 그 사유가 진실이라 하더라도 판결의 효력을 부정하는 주장을 할 수 없다.

III. 상계권 행사의 특수성과 차단효의 적용 여부

1. 학설의 대립

(1) 부정설(비차단설)

- 상계권은 소송상의 방어방법일 뿐만 아니라 실체법상 독립된 형성권이므로, 소송에서 행사하지 않았더라도 그 권리 자체가 소멸하는 것은 아니라고 본다. 따라서 판결 확정 후에도 상계권을 행사하여 집행력 배제를 구할 수 있다는 견해이다.

(2) 긍정설(차단설)

- 변제나 상계나 모두 채권의 소멸을 가져오는 방어방법이라는 점에서는 동일하다. 소송 절차의 안정을 위해 표준시 전에 행사가 가능했던 상계권을 행사하지 않았다면 차단효가 발생한다고 보는 견해이다.

2. 판례의 태도

- “대법원”은 상계권의 행사가 소송 외에서 이루어지든 소송 내에서 이루어지든, 그것이 표준시 이전에 행사가 가능했던 것이라면 기판력의 차단효가 발생한다고 본다. 즉, 채무자가 전소 변론종결 전에 상계 적상에 있었던 채권을 가지고 있었다면, 이를 소송에서 주장하지 않았을 경우 판결 확정 후에 다시 상계권을 행사하여 전소 판결의 집행력을 배제하는 것은 허용되지 않는다는 입장이다.

IV. 사안의 적용

1. 상계 적상의 시점 확인

- 사안에서 피고 乙의 대여금 채권은 2018. 5. 1.이 지급기일이다. 甲이 제기한 소송의 변론종결일은 2018. 12. 1.이므로, 乙은 변론종결 전인 2018. 5. 1.부터 이미 상계 적상에 있었으며 소송 절차 내에서 상계 항변을 할 수 있는 상태였다.

2. 상계권 행사의 제한

- 乙은 충분히 상계 항변을 할 수 있었음에도 불구하고 이를 하지 않은 채 판결이 확정되도록 방치하였다. “판례”의 확립된 견해에 따르면, 표준시(2018. 12. 1.) 이전에 발생한 상계 사유는 기판력에 의해 차단된다. 따라서 乙이 2019. 7. 1.에 이르러 전소 판결에 의한 채무를 면하기 위해 상계를 주장하는 것은 기판력에 저촉되어 허용되지 않는다.

V. 결론

- 피고 乙은 2019. 7. 1.에 상계권을 행사하여 甲에 대한 공사대금 채무를 소멸시킬 수 없다. 비록 乙이 2,000만 원의 진정한 채권을 가지고 있다 하더라도, 이는 전소의 변론종결 전에 이미 행사가 가능했던 방어방법이므로 기판력의 차단효에 의해 행사가 제한되기 때문이다. 乙은 상계권 행사 대신 甲을 상대로 별도의 대여금 반환 청구 소송을 제기하여 자신의 채권을 회수해야 할 것이며, 이미 확정된 공사대금 1억 원의 판결에 대해서는 상계를 이유로 다룰 수 없다. 이하에서는 이러한 기판력의 원칙이 분쟁의 일회적 해결과 확정판결의 권위를 위해 필수적임을 확인한다.